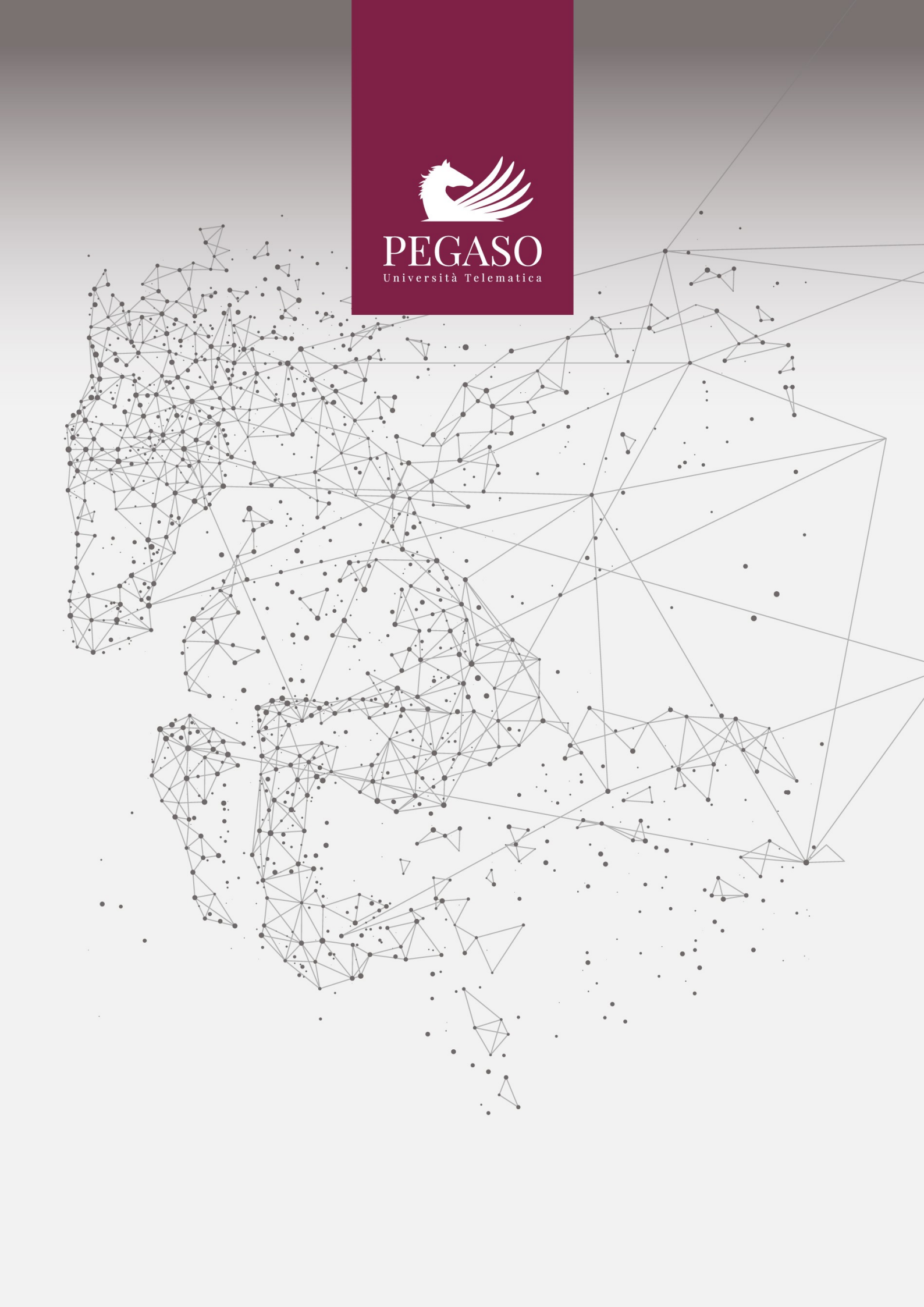

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. IL CASO 3

2. TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI PERSONALI E REGOLE DI RESPONSABILITÀ NEL REGOLAMENTO UE 679/2016 6

3. PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI DI MINORI 14

4. IL RIMEDIO DELL'ART. 614 *BIS* C.P.C. 17

BIBLIOGRAFIA 19

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Il caso

Tribunale di Bari, 7 novembre 2019, n. 6359:

La pubblicazione di una fotografia ritraente una persona, in quanto espressione di un dato personale, è subordinata alla manifestazione esplicita del consenso da parte della stessa, come previsto dagli artt. 10 c.c., 96 l. n. 633 del 1941 e 6 Reg. UE 679/2016. In ragione della natura della causa, dell'illecito e dei soggetti coinvolti, è altresí ammessa l'applicazione di una misura coercitiva indiretta dell'adempimento dell'obbligo, da disporsi a norma dell'art. 614 bis *c.p.c.*

Svolgimento del processo.

Il ricorrente domanda la cessazione della condotta con cui la convenuta ha abusato della di lui immagine e di quella dei suoi figli, perpetrando la pubblicazione di circa mille fotografie sul proprio profilo *Facebook*.

I. 2. – La convenuta, è stata dichiarata contumace all'udienza del 18 dicembre 2017.

II. – La domanda è meritevole di accoglimento.

II. 1. – In punto di fatto vi è prova sufficiente delle circostanze lamentate.

II. 1.1. – In primo luogo vi è prova della pubblicazione sul profilo *Facebook* della convenuta di numerose fotografie ritraenti il ricorrente e i di lui figli. Vi è prova documentale di trentasei album fotografici estratti dal profilo *social* della convenuta e contenenti per lo piú raffigurazioni contestuali delle parti in persona, talvolta anche unitamente ai figli minori del ricorrente. Inoltre, la prova orale ha confermato la pubblicazione effettiva delle suddette foto, sia per il tramite delle dichiarazioni conformi rese dai due testimoni escussi nel corso del giudizio sia per il tramite della conferma della circostanza di fatto che deve desumersi dal comportamento processuale della convenuta; quest'ultima infatti, nonostante la notifica del verbale con cui è stata chiamata a rendere interrogatorio formale, non si è presentata in udienza né ha fatto pervenire idonea giustificazione. Sicché non può revocarsi in dubbio che sul profilo *Facebook* risultano pubblicate le numerose fotografie di cui vi è prova documentale in atti.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

II. 1.2. – In secondo luogo in atti vi è anche prova documentale della spedizione in data 5 dicembre 2016 di una raccomandata con cui, tramite il proprio difensore, il ricorrente ha manifestato inequivocabilmente il proprio dissenso alla (persistenza della) pubblicazione delle foto sul profilo *social* della convenuta.

II. 2. – Ciò chiarito in punto di fatto, deve ritenersi che la condotta della convenuta integra un abuso dell'immagine altrui con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere la cessazione della condotta abusiva e, dunque, la cancellazione dal profilo *Facebook* di (*Omissis*) delle fotografie che ritraggono lui ed i suoi figli minori.

Infatti deve affermarsi in linea generale che la pubblicazione di una fotografia ritraente una persona umana è subordinata alla manifestazione, esplicita o implicita, del consenso da parte della persona ritratta. Tale condizione è prevista sia dalle disposizioni normative a tutela del diritto all'immagine (art. 10 c.c. e art. 96 l. n. 633 del 1941) sia da quelle a tutela del diritto alla riservatezza (art. 6 Reg. UE 679/2016) poiché l'altrui pubblicazione di una propria immagine fotografica costituisce in ogni caso (e a prescindere dall'applicabilità o meno della normativa di tutela di riferimento) una forma di trattamento di un dato personale.

Nel caso di specie, il consenso del ricorrente risulta espressamente negato; o, comunque, ne risulta comunicata la cessazione almeno a far data dal 5 dicembre 2016. La differenza tra negazione e cessazione non è rilevante ai fini che qui occupano poiché il consenso è invero suscettibile di revoca in qualsiasi momento: infatti, i diritti assoluti coinvolti (immagine e riservatezza) hanno natura strettamente personale e, pertanto, non possono soffrire compromissione se non alla luce della continua persistenza ed attualità del consenso, sempre suscettibile di revoca con produzione di effetti *ex nunc*. Salvi, beninteso, i casi in cui la pubblicazione è consentita comunque dalla legge.

Pertanto, nel caso di specie, la condotta della convenuta deve considerarsi del tutto illecita poiché, a fronte della conoscenza dell'espresso dissenso dell'interessato, l'omessa cancellazione delle foto dal proprio profilo *Facebook* realizza un abuso dell'immagine altrui.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

II. 3 – In definitiva, deve essere ordinata la cessazione dell'abuso da parte della convenuta che sarà pertanto tenuta a cancellare dal proprio profilo *Facebook* ogni fotografia ritraente la persona del ricorrente e dei di lui figli.

III. – A fronte della espressa domanda del convenuto deve anche essere prevista una misura di coercizione indiretta dell'adempimento dell'obbligo, da disporsi a norma dell'art. 614 *bis* c.p.c.

In ragione della natura della causa, del rapporto anche pregresso tra le parti e della tenuità dell'illecito, può stimarsi congruo stabilire che la convenuta è tenuta a corrispondere la somma di due euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cancellazione, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

IV. – Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della convenuta che è pertanto tenuta alla rifusione in favore del ricorrente.

Per questi motivi. – Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'àmbito del giudizio R.G. 6359/2017 introdotto da (*Omissis*), con ricorso del 10 aprile 2017 nei con- fronti di (*Omissis*), ogni altra istanza disattesa, cosí provvede:

1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina a (*Omissis*) di rimuovere immediatamente dal proprio profilo *Facebook* ogni fotografia ritraente (*Omissis*) e i di lui figli;

2) Dispone a carico di (*Omissis*) l'obbligo di corrispondere la somma di euro 2,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di rimozione; con decorrenza a far data dalla notifica del presente provvedimento da eseguirsi a cura della parte interessata;

3) Condanna (*Omissis*) alla rifusione di spese e competenze di giudizio che si liquidano in euro 1.951,33 (di cui euro 331,33 per spese) oltre R.S.F. al 15% non- ché I.V.A. e C.P.A. come per legge; pagamento da eseguirsi in favore dello Stato.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Trattamento illecito dei dati personali e regole di responsabilità nel Regolamento UE 679/2016

Nel caso in esame il ricorrente denuncia la pubblicazione, sull'*account* personale della convenuta, di immagini che ritraggono lui e talvolta anche i suoi figli minori sulla nota piattaforma *Facebook*, per un totale di trentasei album fotografici e circa mille fotografie estratte dallo stesso profilo.

La convenuta, «nonostante la notifica del verbale con cui è chiamata a rendere interrogatorio formale, non si presenta in udienza né fa pervenire idonea giustificazione».

Inoltre il ricorrente, tramite il proprio difensore, invia apposita raccomandata con cui manifesta espressamente ed inequivocabilmente il proprio dissenso alla pubblicazione delle suddette foto sul noto *social network*, senza, tuttavia, alcun riscontro positivo. Pertanto, il consenso viene espressamente negato a partire dal 5 dicembre 2016.

Siffatto comportamento viene censurato dal giudice adito, il quale condanna la convenuta ed ordina «la cancellazione di ogni fotografia ritraente la persona ricorrente e dei di lui figli» oltre che «una misura di coercizione indiretta dell'adempimento dell'obbligo da disporsi a norma dell'art. 614 *bis* c.p.c. e la corresponsione di una somma di due euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cancellazione, a far data dalla notifica del presente provvedimento».

Le tematiche dei diritti della personalità e della correlata protezione dei dati personali hanno assunto un ruolo centrale alla luce del quotidiano e sempre più massiccio utilizzo dei *social network* e delle piattaforme di condivisione. Il rischio di perdere il controllo dei propri dati con conseguente esposizione dell'utente ad un pubblico numericamente indefinito e potenzialmente pericoloso, richiede che gli strumenti giuridici tradizionali si adattino e si applichino anche ai rapporti di natura virtuale. Talvolta si tenta di giustificare la prassi di pubblicare immagini sui *social network* senza preventivo e valido consenso dell'interessato, invocando la dematerialità del contesto. Tale circostanza, tuttavia, non esclude la potenziale offensività della condotta.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il diritto all'immagine, quale espressione concreta e forse piú appariscente della personalità, come «cosa ben distinta dalla persona, soggetto del diritto stesso»[1] trova fondamento direttamente nell'art. 2 cost., il quale «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»; esso lungi dall'arrestarsi di fronte al proliferare dei rapporti virtuali si arricchisce di nuova linfa e di più ampi contenuti.

«Domandarsi se il diritto alla riservatezza è un diritto autonomo o no finisce con l'essere un falso problema poiché la riservatezza non è altro che un aspetto essenziale dello sviluppo della persona umana e come tale non esprime altro che un valore fondamentale dell'ordinamento[...] non vi è allora un problema di diritto alla riservatezza ma vi è solamente un problema di tecniche diverse, tutte utilizzabili per realizzare un valore, quello della persona umana»[2].

Anche l'art. 10 c.c. si pone quale referente centrale del diritto all'immagine (sia in ambito materiale sia virtuale): esso infatti vieta la pubblicazione o l'esposizione dell'immagine di una persona, dei genitori, del coniuge o dei figli fuori dai casi espressamente previsti dalla legge e prevede la possibilità di adire l'autorità giudiziaria per chiedere la cessazione della condotta abusiva, salvo il risarcimento del danno. A garanzia di una effettiva e rafforzata tutela verso i minori e, piú in generale, in un'ottica costituzionalmente orientata di solidarietà familiare, tale esercizio viene esteso anche ai genitori.

L'articolo 10 c.c. va letto anche alla luce degli artt. 96 e 97 l. n. 633 del 1941 (legge sul diritto d'autore) i quali disciplinano rispettivamente i diritti relativi al ritratto (incluse le riproduzioni che, anche se indirette, riconducono al soggetto) ed i casi in cui la circolazione di immagini non necessita di espresso consenso del soggetto coinvolto, come nella diffusione di immagini ritraenti soggetti noti o personaggi dello spettacolo.

Ai sensi dell'art. 97 l. aut., in particolare, «non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto,

[1] F. CARNELUTTI, *Diritto alla vita privata (contributo alla teoria della libertà di stampa)*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1955, p. 5 ss.

[2] P. PERLINGIERI, *La persona e i suoi diritti*, *Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, p. 252 ss.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta».

Per evitare la illiceità della riproduzione sono necessari taluni elementi: la notorietà del soggetto ritratto, la finalità informativa per cui avviene la diffusione, la modalità della pubblicazione e il tenore della descrizione e della terminologia usate.

Quanto, in particolare, alla ricorrenza del requisito della notorietà, essa investe la vita di una persona nella sua totalità, dalla professione alla sfera piú intima, ragion per cui l'ordinamento giuridico consente la circolazione di immagini anche senza il consenso dell'interessato, solo in relazione alle attività di pubblico interesse attinenti la professione o carica istituzionale ovvero ai singoli fatti ed atti connessi. In tutti gli altri casi, al contrario, il consenso deve ritenersi indispensabile e deve essere prestato in modo chiaro ed inequivocabile.

Viene cosí in rilievo l'importanza sancita dall'art. 96 l. aut. ai sensi del quale "Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente".

La stretta correlazione tra la tutela dell'immagine e la dignità della persona fa si che «la circolazione dell'immagine e del nome, data la loro natura non può essere senza limiti»[3]. Questo ancor più nel contesto attuale dominato dalla rete Internet ed i *social network* che sono ormai parte integrante della nostra quotidianità, sono il nostro modo di vivere e condividere, ma il prezzo da pagare in termini di *privacy* talvolta è molto alto: la rete scava dentro di noi e ne "estrae" tutte le informazioni piú intime, instaurando con ciascun utente che vi si approccia uno strano quanto controproducente meccanismo per cui "per avere devi dare", per "accedere devi dire" ed in cui la pericolosità degli esiti che ne possono derivare è sempre piú alta[4].

[3] F.G. VITERBO, *Protezione dei dati personali e autonomia negoziale*, Napoli, 2008, p. 48.

[4] E. STELLA, *Quando si pubblica su* Facebook *senza consenso. Sulla violazione del diritto all'immagine e sulla tutela dei dati personali (anche dei minori)*, in *Tecnol. dir.*, 2021, p. 267.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Tali premesse tornano utili per affrontare un aspetto chiave della sentenza in epigrafe. Procedendo con la lettura del testo, per l'appunto, si legge «in linea generale la pubblicazione di una fotografia ritraente una persona umana è subordinata alla manifestazione, esplicita o implicita, del consenso da parte della persona ritratta».

I fondamenti della liceità sono da ravvisarsi nel consenso dell'interessato e nella necessità del trattamento medesimo, che devono poi completarsi con l'intero processo di valutazione disciplinato dall'art. 5 del reg. (UE) 679/2016.

In particolare l'art. 5 del Regolamento specifica, alla lett. *a*, che i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente. La garanzia di liceità assolve una duplice funzione, individua l'*an* del trattamento e costituisce il principio generale in base al quale valutarne la legittimità.

Per quanto riguarda il consenso, esso consiste in una «qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato» (art. 4 reg. Ue)

Rispetto al passato, il Regolamento ha apportato una modifica significativa: il consenso diviene vera e propria condizione di legittimità del trattamento dei dati stessi. Esso deve essere libero e sempre esplicito (anche per i trattamenti automatizzati); l'interessato non è piú chiamato ad "accettare", ma a «manifestare il proprio assenso mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento» (art. 4 lett. 11). In tale direzione, il consenso dell'interessato implica che tutte le informazioni necessarie allo scopo del trattamento medesimo siano rese con un linguaggio semplice e chiaro e che non lascino dubbi circa la sua reale volontà, prima ancóra che il trattamento venga effettuato, secondo il principio di inequivocabilità.

Si riconosce al consenso una duplice finalità: esso è contestualmente garanzia di libertà delle scelte dell'individuo e garanzia di tutela della persona stessa, della quale ne rappresenta la proiezione nella società dell'informazione e nella rete, attraverso la protezione dei dati personali e la relativa diffusione; essi, infatti, come sottolinea il giudice *de quo*, «non possono in alcun modo essere compromessi se non alla luce di una continua persistenza ed attualità del consenso e salvi i casi in cui la pubblicazione è regolarmente consentita dalla legge».

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

È dunque imprescindibile porre l'accento in ordine a tutte quelle situazioni in cui il consenso non possa considerarsi valido perché oggetto di forzatura, ovvero quando non sia mai stato prestato.

Nel caso in esame, «il consenso del ricorrente risulta espressamente negato; o, comunque, ne risulta comunicata la cessazione almeno a far data dal 5 dicembre 2016». Circostanza, questa, che consente al ricorrente di promuovere un'azione volta ad ottenere il risarcimento per trattamento illecito dei dati personali e il diritto alla cancellazione delle foto.

Quanto al profilo della responsabilità, il Regolamento ha uniformato le relative regole in caso di trattamento illecito dei dati personali stabilendo all'art. 82 che «chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento[5] o dal responsabile del trattamento[6]» e che «il responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento» (par. 2). Al contrario, «il titolare del

[5] Il titolare è colui che «singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento» (art. 4 n. 7 Regolamento) e risponde «per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento». La responsabilità del titolare è ovviamente piú ampia rispetto a quella del responsabile poiché è il primo a porre in essere il trattamento, definendo altresí finalità e modalità. Egli è responsabile dei danni per il fatto stesso di aver dato luogo al trattamento, indipendentemente da chi lo abbia materialmente posto in essere. Il considerando n. 74 del Regolamento infatti afferma che la «responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto». L'art. 82, par. 4, inoltre, stabilisce che se piú titolari o piú responsabili o un titolare e un responsabile del trattamento sono coinvolti nello stesso trattamento nel senso che ne abbiano determinato congiuntamente le modalità e le finalità, essi sono considerati «contitolari del trattamento» (art. 26 Regolamento) e saranno responsabili in solido per i danni cagionati, rilevando la misura dell'attività di trattamento concretamente eseguita dall'uno o dall'altro solo ai fini del riparto interno di responsabilità. Diverso è il caso in cui un titolare condivida i dati a sua disposizione con un altro titolare, affinché questi possa eseguire un trattamento del tutto autonomo. Nei limiti in cui tale condivisione sia lecita, in questo caso il primo titolare non potrà essere considerato responsabile per i danni cagionati nel corso del trattamento effettuato dal secondo titolare, dato che non si tratta di un «suo» trattamento.

[6] Il responsabile è «colui che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento» (art. 4 n. 8 Regolamento) e risponde «solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento».

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2, se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile».

Alla luce della disciplina che si ricava dalla norma in esame è evidente che la condotta della convenuta sia chiaramente abusiva. La raccolta attraverso il suo profilo *Facebook* di trentasei album fotografici ritraenti il ricorrente ed i suoi figli e la diffida presentata da quest'ultimo con cui dichiara di non aver mai prestato il suo consenso rispetto a tale attività e chiede la contestuale cancellazione delle foto, si aggiungono al fatto che «nonostante la notifica del verbale con cui è stata chiamata a rendere interrogatorio formale non si è presentata in udienza, né ha fatto pervenire idonea giustificazione». Pertanto, le evidenti inosservanze poste in essere e l'inconsistenza di una prova liberatoria, realizzano a suo carico l'abuso dell'immagine altrui e la conseguente responsabilità civile.

L'impianto dell'art. 82 reg., pone come elementi costitutivi della fattispecie la violazione del Regolamento, la qualificazione dei soggetti coinvolti, il nesso causale tra la violazione ed il danno che ne deriva e la liquidazione del danno risarcibile.

Con riguardo ai soggetti, il Regolamento li circoscrive al responsabile ed al titolare − allontanandosi sensibilmente dalla tradizionale e generica formula del "colui" propria dell'art. 2043 c.c. – i quali rispondono di una qualsiasi violazione, cioè di un qualsiasi trattamento che non sia incluso nel perimetro di liceità disciplinato, oltre che degli specifici obblighi rilevanti ai fini dell'onere probatorio. Ai sensi dell'art. 24 e del considerando n. 32 essi consistono in «misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e a dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al presente Regolamento»: in sostanza, laddove vi sia stata una violazione, il titolare o responsabile può esonerarsi da responsabilità dimostrando il verificarsi di un caso fortuito o di forza maggiore oppure di aver adottato tutte le misure tecniche disponibili atte a ridurre il rischio (sempre che il rischio di verificazione dei danni e l'entità degli stessi fossero sufficientemente bassi, dovendosi altrimenti astenere dal trattamento), o che i costi delle misure di prevenzione erano eccessivi rispetto a una bassa probabilità e/o gravità del rischio stesso.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il meccanismo si fonda sulla responsabilizzazione del titolare/responsabile del trattamento in base al principio dell'*accountability* in virtú del quale in presenza di un trattamento "anomalo", incombe su chi tratta i dati l'onere di dimostrare che al contrario esso è lecito.

Il legislatore ha inteso applicare la norma avendo di volta in volta riguardo al titolare del trattamento, alla natura dei dati trattati e al trattamento in sé considerato: l'*accountability* è un nuovo approccio preventivo e responsabile nella gestione della protezione dei dati e segna «l'emersione di complessi doveri di gestione e prevenzione differenziati in base al rischio specifico correlato al peculiare trattamento dei dati personali posto in essere»[7].

Per quanto, invece, attiene al profilo del risarcimento, il Regolamento prevede la risarcibilità del danno «immateriale» quale sinonimo del danno non patrimoniale. Alcuni esempi di danni risarcibili secondo il Regolamento possono ricavarsi dal considerando n. 75 in riferimento ai rischi che dai trattamenti possono derivare, «in particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo [...] o se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori». Similmente, il considerando n. 85 afferma che la violazione dei dati personali può «provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata».

L'esigenza avvertita dal legislatore europeo e tradotta nell'art. 16 reg. è quella di offrire una tutela realmente efficace dei diritti fondamentali messi a dura prova dai mercati digitali. La previsione della risarcibilità dei danni non patrimoniali si iscrive, dunque, nella volontà di garantire un effettivo e giusto ristoro al soggetto danneggiato, una giusta tutela tramite regole di liceità,

[7] E. TOSI, *Illecito trattamento dei dati personali, responsabilizzazione, responsabilità oggettiva e danno nel GDPR: funzione deterrente-sanzionatoria e rinascita del danno morale soggettivo*, in *Contr. impr.*, 2020, p. 1144

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati personali immediatamente protettive dell'interessato e regole di liceità, correttezza e trasparenza indirettamente protettive del mercato e dell'ordinamento giuridico in generale.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Pubblicazione di immagini di minori

Particolarmente significativa è la circostanza che la pubblicazione di immagini riguardi anche i figli minori dell'attore.

Sono numerose le fonti, anche sovranazionali, che affrontano il tema del diritto alla tutela del minore. Già sul finire degli anni '80, la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con la l. 27 maggio 1991, n. 175, mostra consapevolezza e sensibilizzazione verso il potenziale lesivo dei *media* nella crescita e nella formazione dei minori.

Nella stessa direzione, la Convenzione europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996 sull'esercizio dei diritti del minore, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, meglio conosciuta in Italia come Carta di Nizza del 7 dicembre 1990, fino a giungere al Codice della Privacy relativo alla protezione dei dati personali del minore (anche in campo giornalistico), alla l. 29 maggio 2017, n. 71 contro il *cyber bullismo* fino al piú recente Regolamento UE 679/2016.

Il limite del descritto quadro normativo, tuttavia, era rappresentato dalla circostanza che in quelle normative il raggiungimento di una determinata età era assunto come unico parametro per distinguere i vari livelli di evoluzione e maturità psico-fisica del soggetto; in altre parole, la progressiva capacità dello stesso di poter compiere atti e determinarsi in ordine alle vicende della sua vita dipendeva dal riferimento astratto all'età.

Una visione, questa, che sebbene fedele all'impianto dell'art. 2 c.c. (ai sensi del cui primo comma "La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa"), risultava inevitabilmente in contrasto con un sistema ordinamentale fondato sulla libertà e sul pieno sviluppo della persona.

Sul punto, il Reg. UE 679/2016, offre una soluzione diversa e certamente apprezzabile in quanto riconosce al minore uno spazio di autonomia decisionale, una consapevole capacità di discernimento ed un suo diritto di autodeterminazione nelle proprie azioni nonché nelle relative conseguenze.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In altre parole, si avverte l'importanza di verificare in concreto la gradualità dello sviluppo della persona e, di conseguenza, riconoscere l'idoneità del soggetto a compiere validamente delle scelte inerenti la propria esistenza, a prescindere dal riferimento al criterio dell'età. Si evita, in tal modo quel passaggio repentino da una incapacità assoluta ad una capacità totale e, al contrario, si favorisce il passaggio dalla minore alla maggiore età in maniera graduale ed articolata.

L'art. 8 GDPR, denominato appunto «Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione» stabilisce che il consenso al trattamento dei dati personali del minore è lecito a partire dal compimento del sedicesimo anno d'età, prima del quale, sarà valido solo se prestato o autorizzato dai genitori o da chi ne esercita la resonsabilità genitoriale, facendo salva la possibilità agli Stati membri di derogarvi con apposita disposizione di legge.

La norma sancisce il diritto del minore ultra sedicenne a mantenere il controllo circa la divulgazione e l'utilizzo delle proprie informazioni nella rete, ritenute ormai vere e proprie forme di rappresentazione della vita personale e quindi dell'identità.

La scelta del legislatore europeo di individuare una sorta di "maggiore età digitale" consente evidentemente di apprestare una tutela realmente efficace per i minori d'età, senza limitare in modo eccessivo tali soggetti nell'esercizio dei propri diritti, ma al contrario valorizzando alla luce delle circostanze concrete i loro poteri di autodeterminazione e discernimento.

Nella direzione della valorizzazione della personalità del minore si pone anche l'art. 315 bis c.c., che realizzando compiutamente l'indirizzo costituzionale in tema di diritti fondamentali, pone in luce il diritto del minore ad essere ascoltato in tutti i procedimenti e le questioni che lo riguardano purché dimostri capacità di discernimento; pertanto indipendentemente dal compimento di un predeterminato anno d'età.

In questa prospettiva emerge, altresì, la necessità di riequilibrare il rapporto tra il minore ed il genitore nell'esercizio dei suoi doveri individuando nella garanzia del *best interest* del minore il limite entro cui può spingersi il controllo genitoriale. Si passa così da una condizione di soggezione

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ad una condizione di protezione del minore, che il genitore deve educare, curare e seguire in ogni sua fase ed attività, ma sempre nel rispetto delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Il rimedio dell'art. 614 *bis* c.p.c.

Nella decisione in commento, come già argomentato, il giudice ordina la cessazione della condotta illecita e l'immediata cancellazione delle foto che ritraggono il ricorrente e talvolta i suoi figli minori con l'ulteriore obbligo «di corrispondere la somma di euro due per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cancellazione, a far data dalla notifica del presente provvedimento». Con l'aggravante che la condotta lesiva posta in essere dalla convenuta si è reiterata anche dopo l'espresso dissenso manifestato dal ricorrente.

L'art. 614 *bis* c.p.c. configura una misura coercitiva indiretta accessoria ad un provvedimento di condanna, con cui l'organo giudicante stabilisce il pagamento di una somma di denaro per violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione di un obbligo di fare infungibile o di non fare e, pertanto, collegata ad ogni frazione di tempo in cui si verifica il ritardo nell'inadempimento, piuttosto che ad ogni episodio di violazione dell'obbligo di astensione: un rimedio generale, adattabile anche ai contesti esofamiliari che mira a garantire l'effettività della tutela che si chiede nel giudizio di merito. Si tratta, in altre parole, di uno strumento a servizio del processo volto ad assegnare il massimo di effettività ai provvedimenti di condanna e ad evitare che la loro attuazione risulti rimessa alla mera conformazione spontanea da parte del debitore.

Se questa è la funzione della norma in esame occorre domandarsi se, nel caso in esame, sia stata correttamente applicata e se la misura disposta dal giudice sia in grado di garantire l'effettività della tutela cui il legislatore tende.

La possibilità per la vittima, o – per utilizzare la terminologia del GDPR – per l'interessato, di ottenere il risarcimento del danno deve concretizzarsi nel ristoro equivalente al pregiudizio complessivamente subíto, tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto l'alterazione peggiorativa della sua vita relazionale in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, pur riconoscendosi l'oggettiva difficoltà della quantificazione in prestazione pecuniaria dei valori offesi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Se tanto è vero, pare potersi concludere che l'*astreinte* di cui all'articolo 614 *bis* c.p.c., non realizza a pieno la sua funzione a tutela della parte lesa, pur nascendo quale rimedio certamente valido ad evitare ulteriori danni specie in circostanze che coinvolgono un minore.

In particolare, nella sentenza in esame, il riferimento operato dai giudici alla «la tenuità dell'illecito» e la condanna al pagamento della «somma di euro due» cadano in estrema contraddizione con il fine che si vuole raggiungere e che viene piú volte rimarcato in tutto il testo della sentenza, finendo per sbiadire sensibilmente la portata dei diritti lesi e relegare il ruolo dei dati personali ad una pura dimensione economica. Senza considerare che in tal modo si può generare l'ulteriore rischio di dissuadere i soggetti lesi dalla volontà di agire in giudizio nonostante l'ormai nota natura fondamentale e meritevole di protezione dei succitati diritti e contestualmente di avallare le contrapposte condotte antigiuridiche portando i trasgressori a sottovalutare la gravità delle loro azioni.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- E. Stella, *Quando si pubblica su* Facebook *senza consenso. Sulla violazione del diritto all'immagine e sulla tutela dei dati personali (anche dei minori)*, in *Tecnol. dir.*, 2021, p. 267.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).